

1500173-40.2022.8.26.0240

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Arthur Lutiheri Baptista Nespoli

Comarca: Iepê

Foro: Foro de Iepê

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... já assentou o STJ, o objetivo da figura do tráfico privilegiado: é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida. Nesse contexto, o aludido § 4º do art. 33, ao prever que o acusado não deve se dedicar a atividades criminosas, não exige, em nenhum momento, que essa dedicação seja exercida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Iepê

Foro de Iepê

Vara Única

Rua: Minas Gerais, 343, Iepe-SP - cep 19640-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500173-40.2022.8.26.0240 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500173-40.2022.8.26.0240

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2214625/2022 - DEL.POL.NANTES, 26615434 - DEL.POL.NANTES, 2214625 - DEL.POL.NANTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVELYN DA SILVA GABRIEL

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Arthur Lutiheri Baptista Nespoli

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra EVELYN DA SILVA GABRIEL, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 08 de agosto de 2022, por volta das 11h24min, na Rua Clementino, nº 10, no município de Nantes, comarca de Iepê, trazia consigo e transportava, para entrega a consumo de terceiros, 24 (vinte e quatro) porções - seis invólucros e dezoito tijolos - contendo em seu interior cannabis sativa L, entorpecente popularmente conhecido como "maconha", pesando aproximadamente 16,270 kg (dezesesseis quilos e duzentos e setenta centigramas), droga capaz de causar dependência física e psíquica, conforme Portaria da ANVISA nº 344/1998, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 21/22, fotografias de fls. 23/30 e laudo pericial de exame químico-toxicológico de fls. 112/114. Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e espaço retro mencionadas, a

denunciada estava dentro de um ônibus de transporte coletivo que havia saído da cidade de Maringá, no Estado do Paraná, com destino à cidade de Marília, no Estado de São Paulo, quando foi interceptada por policiais militares que estavam em seus deveres de ofício averiguando o ônibus, ocasião em que foram encontradas com ela os entorpecentes acima descritos.

Com efeito, a Polícia Militar recebeu uma notificação via Copom relatando que uma passageira do ônibus Princesa do Norte, que fazia o trajeto Maringá-PR/Marília-SP, estava transportando drogas.

Diante dessas informações, os milicianos se dirigiram ao local em que estava o ônibus, nas proximidades da Lanchonete Patinhas, no município Nantes, e adentraram-no para averiguações, instante em que a denunciada fez um movimento brusco, colocando coisas dentro de uma bolsa marrom, chamando a atenção dos agentes, motivo pelo qual foi abordada e solicitado a ela que abrisse referida bolsa, momento em que os policiais lograram encontrar três porções de maconha.

Na sequência, a denunciada foi encaminhada para fora do ônibus e indagada, afirmou que existia mais drogas na bolsa que estava no bagageiro, onde foram encontradas mais uma porção e outros dezoito tijolos de maconha, tendo Evelyn confessado que adquiriu o entorpecente na cidade de Maringá-PR e que as entregaria somente na cidade de Marília-SP, sendo então presa em flagrante delito e conduzida à Delegacia de Polícia, restando configurado, ademais, o tráfico entre Estados da Federação.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01).

Boletim de ocorrência (fls. 06/08 e 47/49).

Auto de exibição e apreensão (fls. 10/13 e 50/51).

Fotografias (fls. 23/30).

Termo de audiência de custódia (fls. 52/58), ocasião em que foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva da acusada.

Laudo pericial (fls. 112/114).

Relatório final (fls. 136/138).

A denúncia foi recebida em 20 de setembro de 2022 (fls. 165/170).

Notificada (fls. 172), a denunciada apresentou defesa prévia, pugnando pela rejeição da denúncia (fls. 155/159).

No Habeas Corpus de nº 2243733-32.2022.8.26.0000 foi indeferida a medida liminar (fls. 192/196).

Designou-se audiência de instrução para o dia 07 de novembro de 2022, ocasião em que foram ouvidas uma testemunha de acusação, uma testemunha de defesa, bem como ocorreu o interrogatório da acusada (fls. 231/232).

O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela procedência da pretensão punitiva com a condenação da acusada, nos termos da denúncia.

A Defesa, em memoriais escritos, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal, assim como que seja reconhecida a atenuante da confissão, requereu a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, a fixação do regime aberto e a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 236/266).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, procedo à emendatio libelli para adequar a tipificação dos fatos ao art. 33, caput, c/c art. 40, III e V, todos da lei nº 11.343/06, uma vez que a acusada foi flagrada na prática de tráfico de entorpecentes interestadual em transporte público.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08 e 47/49), auto de exibição e apreensão (fls. 10/13 e 50/51), fotografias (fls. 23/30), laudo pericial (fls. 112/114), relatório final (fls. 136/138), bem como pela prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

A autoria é certa e recai sobre a acusada.

A testemunha de acusação Fabio Hatschabach Capuano, policial militar, em juízo, ratificando o que disse em sede inquisitiva (fls. 02) afirmou que recebeu uma ocorrência via copom, avisando que um ônibus que estaria de passagem no município

estava com uma passageira transportando drogas. Disse que localizaram o veículo, sendo que foi realizada a abordagem e passou-se a busca dentro do referido ônibus. Relatou que a acusada demonstrou estar nervosa e tentando esconder o rosto, sendo então abordada e revistada. Narrou que foi localizado uma quantidade de maconha e na mala que estava no bagageiro encontraram grande quantidade de entorpecente, com peso total de 16 quilos. Declarou que o ônibus vinha de Maringá sentido interior, e não foi encontrado passagem nos pertences da acusada. Aduziu que a ré estava indo para Marília e declarou que iria ganhar com o transporte um tablete e meio daquela droga e um valor em dinheiro.

A testemunha de defesa Kailaine Vitoria Oliveira Pires, em juízo, afirmou que conhece a acusada desde os treze anos de idade e que ela é solteira e possui dois filhos. Relatou que um dos filhos se encontra com avó paterna e a outra filha com o avó materna. Narrou que a acusada é usuária de entorpecentes. Narrou que a ré nunca se envolveu com crimes.

A acusada Evelyn da Silva Gabriel, em sede inquisitiva (fls. 04), alegou que foi contratada por um desconhecido para levar a droga em questão de Maringá-PR até Marília-SP, e que receberia um tijolo e meio da maconha transportada. Em juízo, confirmou os fatos. Disse que estava transportando os entorpecentes para a cidade de Marília, sendo que vinte e quatro porções era para seu uso. Alegou que iria receber pelo transporte R\$ 2.000,00. Afirmou que não conhecia a pessoa que lhe entregou os entorpecentes, apenas foi colocado em sua mala e foi entregue sua passagem. Narrou que é usuária de drogas há cinco anos. Relatou que foi a primeira vez que aceitou fazer o transporte por estar desempregada. Declarou que sempre trabalhou mas ficou desempregada recentemente.

Analisando o conjunto probatório, restou evidenciado que a ré praticou o crime a ela imputado na exordial acusatória (artigo 33, "caput", c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06).

A autoria do fato restou cabalmente demonstrada pelo depoimento dos policiais, os quais foram uníssimos em afirmar que encontraram o entorpecente na posse da ré; aduziram que em sua bolsa marrom havia três porções razoáveis de maconha; que em sua bolsa no bagageiro havia mais dezoito tijolos inteiros mais meio. A própria acusada assumiu a propriedade de todo entorpecente consigo encontrado.

A finalidade mercantil restou evidenciada pela quantidade, natureza, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, bem como pela própria confissão da acusada, ao esclarecer que estava transportando o entorpecente de Maringá/PR para Marília/SP. Acrescentou que receberia R\$ 2.000,00 pelo transporte e que ganharia parte da droga como pagamento.

Note-se ainda que, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal. E, na espécie, a ré infringiu a norma do art. 33 por, ao menos, trazer consigo e transportar, para entrega a consumo de terceiros substância entorpecente, cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova.

Ademais, os relatos dos policiais são válidos, pois são servidores públicos que, ao tomarem posse, assumem o compromisso de cumprirem com retidão os seus deveres funcionais, agindo em regra de forma correta e nos limites legais, servindo os depoimentos como meio de prova idôneo, principalmente quando tomados em juízo, até que se prove ao contrário, ônus que cabe à defesa (STJ - HC nº 165.561/AM, rel. Min. Nélfi Cordeiro, j. 2.2.2016).

Pela prática adquirida com a profissão por eles desempenhada, os policiais são capazes de apontar fatos e circunstâncias imprimidas nas diligências levadas a efeito para elucidar o acontecido, só deles conhecida, que culminam por trazer a certeza do cometimento imputado, especialmente quando as versões por eles descritas são anotadas logo de início no auto de flagrante e não desmerecidas no contraditório.

Registre-se que, além de não demonstrado o interesse em prejudicar a acusada, o depoimento deles "pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte". (STJ HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 -IMPOSSIBILIDADE - Inviável a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade e variedade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais militares quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu - Recurso não provido. (Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 10/08/2016; Data de registro: 23/08/2016) (negritou-se).

"Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal" (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1º TURMA, HC.nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 11.04.97).

Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Com vistas a se elucidar a questão relativa à pequena ou grande quantidade de drogas apreendidas, tomemos a lição de Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio, in verbis: "Lembre-mos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,4 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente." (Moraes, Alexandre de, Legislação Penal Especial, 10ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, página 114). (grifou-se).

No caso, com a ré fora apreendido mais de 16 kg de maconha. Em sigelo cálculo, verifica-se a possibilidade de confecção de mais de 49.300 cigarros da droga (16,270g/0,33g). De todo modo, mesmo em se admitindo a confecção do cigarro com a generosa quantidade de 1g, ainda assim seria o equivalente a cerca de 16.000 unidades, o que denota íntimo envolvimento com as atividades criminosas.

No mais, "eventual condição de usuário do apelado não afasta, por si só, a incidência do delito de tráfico de drogas, visto ser plenamente possível e comum, encontrar, em uma mesma pessoa, as figuras de usuário e traficante, sem que com isso o agente saia ileso do crime de maior gravidade" (TJSP Apelação Criminal nº 1500068-38.2018.8.26.0617, Rel. Des. Roberto Porto, j. 28.02.2020).

Segue o entendimento do C. STJ:

"(...) Destaco ainda, que muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente. A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde

pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde: ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas." (STJ - REsp1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, data de publicação: 06.03.2018).

Observo, ademais, não ser o caso de se reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no § 4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06. Inviável sua aplicação, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais.

Outrossim, não se pode descurar da gravidade do delito imputado, revelando a periculosidade da ré, uma vez que foi flagrada quando trazia consigo e transportava, para entrega a consumo de terceiros, 24 porções (seis invólucros e dezoito tijolos) de cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", pesando 16,270 kg.

Saliente-se que o dispositivo em comento trata da figura do "traficante privilegiado", também chamada de "traficância menor" ou "traficância eventual", no qual estabelece a redução de pena de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Como já assentou o STJ, o objetivo da figura do tráfico privilegiado: é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida. Nesse contexto, o aludido § 4º do art. 33, ao prever que o acusado não deve se dedicar a atividades criminosas, não exige, em nenhum momento, que essa dedicação seja exercida com exclusividade. Portanto, a aplicação da minorante é obstada ainda que o agente exerça, concomitantemente, atividade profissional lícita. (REsp 1.380.741-MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe 25/4/2016).

Restou perfeitamente configurado, enfim, o tráfico de entorpecentes, resultado da conjugação dos depoimentos dos policiais, com a confissão da acusada, as circunstâncias da prisão, a natureza, a quantidade e o modo de acondicionamento do entorpecente, a revelar o intuito mercantil.

Outrossim, verifica-se que a quantidade e valor das drogas apreendidas com a ré são absolutamente incompatíveis com sua renda (desempregada), o que denota envolvimento com organização criminosa, fornecedora da substância para venda a terceiros e lucro compartilhado.

Nesse contexto, a dedicação ao tráfico como meio de vida ou fonte de complementação da renda impede a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4.º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006, destinada apenas ao traficante novato, neófito, o "traficante de primeira viagem", nas palavras de GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Leis Penais Especiais, RT, 2.ª edição, 2007, p. 330).

Sob um segundo enfoque, tem-se que a quantidade e nocividade dos tóxicos (maconha, mais de 16 kg) denotam estreito vínculo com organização criminosa (somente pessoa profundamente enfronhada no "mundo do crime" pode obter tamanho volume de droga suficiente para abastecer grande número de incautos usuários), circunstância apta a delinear dolo intenso igualmente incondizente com o privilégio (STF, RHC 94.806/PR; STJ, HC 105.216/SP e HC 141.921/SP; TJESP, Apelação Criminal nº. 0006187-64.2012.8.26.0176, Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO).

No caso em questão, dada a quantidade de entorpecentes apreendida em transporte com a acusada (16 kg de maconha, em porções e tijolos), inaplicável a referida causa especial de diminuição de pena. Tal montante de drogas aponta maior ofensa ao bem jurídico tutelado, tendo em conta que viabiliza universo maior de consumidores; ademais, não se obtém esta expressiva quantidade de entorpecente de tal valor econômico de forma fortuita, em qualquer canto de uma "biqueira", fazendo pressupor que haja, no mínimo, atuação delituosa que envolva fornecedor e receptor das drogas apreendidas e consequente envolvimento com a traficância, do que decorre dedicação a atividades criminosas.

Tais circunstâncias demonstraram que a ré se dedicava à atividade criminosa de maneira habitual, até porque traficantes iniciantes e eventuais não teriam o poder econômico para adquirir tamanha quantidade de entorpecente, nem a eles seria confiada quantidade expressiva de drogas pelo seu proprietário. Basta mero cálculo aritmético para se aferir a veracidade da conclusão. Em estando transportando mais de 16 kg de maconha, tem-se que com essa quantidade de droga possível a confecção

de 16.000 porções individuais ou cigarros de 1g. Cada porção/cigarro é vendida(o) no valor médio que varia de R\$ 5,00 a R\$ 10,00, donde se conclui que a ré transportava mercadoria espúria no valor de R\$ 80.000,00 a R\$ 160.000,00. Resulta óbvio que esse montante de entorpecente não seria entregue a pessoa desvinculada da cadeia criminosa, em quem não se depositasse confiança na guarda da droga. Nesse sentido:

"Apelação criminal Tráfico de entorpecente Sentença condenatória Preliminar de nulidade do processo em face da oitiva das testemunhas de acusação na ausência do réu Rejeição Oitiva realizada por carta precatória Defesa intimada do ato, quedando-se inerte Não comprovação de prejuízo. No mérito, pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, a concessão do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, a exclusão da causa de aumento e a fixação de regime mais brando Inadmissibilidade e autoria suficientemente demonstradas Materialidade Grande quantidade de maconha apreendida Depoimentos dos policiais coerentes e convincentes, de suma importância na elucidação dos fatos Comprovação de que a substância entorpecente era transportada entre Estados da Federação. Mantida a causa de aumento do tráfico interestadual. Condenação bem imposta, com base em sólido e convincente acervo probatório. Penas básicas nos mínimos legais. Incabível a incidência do privilégio do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que a grande quantidade de entorpecente demonstra a dedicação do agente a atividade criminosa. Gravidade concreta da conduta, decorrente da elevada quantidade da substância apreendida, que revela elevada danosidade social, a obstaculizar, portanto, ao lado do quantum punitivo, a conversão da pena corporal em restritivas de direitos, servindo, de resto, como justificativa de imposição de regime mais severo. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Criminal 1500267-61.2019.8.26.0573; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itatinga - Vara Única; Data do Julgamento: 18/04/2022; Data de Registro: 18/04/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso defensivo - Pleito de redução da pena -- Descabimento - Penas adequadamente fixadas tendo em vista as condições desfavoráveis - Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a grande quantidade de drogas encontradas em seu poder - Incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, V da Lei 11343/06, pois bem caracterizado o tráfico interestadual pelos depoimentos das testemunhas policiais - Regime inicial fechado único adequado no caso - [...]. (TJSP; Apelação Criminal 1500620-38.2019.8.26.0594; Relator (a): Fátima Vilas Boas Cruz; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Agudos - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 17/10/2022; Data de Registro: 17/10/2022)

Diante de caso semelhante, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que a quantidade e a nocividade da droga apreendida, bem como as circunstâncias em que foi o agente surpreendido, por si sós, indicam maior periculosidade social da ação, outro obstáculo à incidência da causa de redução (HC nº 182.359/RJ, julgado 27-11-2012).

Aliás, é cediço que para que se possa praticar qualquer das condutas previstas no "caput" do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 não é suficiente a mera predisposição do agente para tanto. Não se consegue droga em grande quantidade em qualquer lugar. O traficante não pode efetuar a venda de entorpecentes onde bem entende, a menos que esteja sob a autorização da organização criminosa que controla a atividade ilícita na região. Caso contrário, sofrerá represálias.

A causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06 deve ser reconhecida. O tráfico é interestadual, haja vista que a ré declarou que adquiriu o entorpecente na cidade de Maringá/PR e entregaria na cidade de Marília/SP. A acusada fora presa em flagrante na cidade de Nantes/SP, já tendo, inclusive atravessado a fronteira entre Paraná e São Paulo.

A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06 também deve ser reconhecida. A acusada fora presa em flagrante transportando a droga dentro do ônibus da viação Princesa do Norte. Trazia o entorpecente em bolsa e bagagem. Sobre a referida causa de aumento, não se desconhece posição não vinculante no

sentido de se exigir a efetiva comercialização do transporte público para sua caracterização. Contudo, respeitado posicionamento diverso, o art. 40, III, da Lei 11.343/06, especifica que a reprimenda será majorada se “a infração tiver sido cometida (...) em transportes públicos”. Ora, é cediço que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e conteúdo variado, de modo que a prática de qualquer dos núcleos típicos do art. 33, da Lei 11.343/06, é suficiente para a configuração do delito, sendo prescindível, portanto, que o agente seja flagrado enquanto vende ou efetua a entrega da droga. Assim sendo, qualquer conduta (inclusive o simples transporte do entorpecente) que caracterize o crime de tráfico de drogas, desde que cometida no transporte público, é suficiente para a incidência da majorante. Se a mercancia não é exigível para a caracterização do tráfico, não pode o ser para a configuração da causa de aumento de pena, quando do uso do transporte público. Vale frisar que se o legislador almejasse restringir o alcance da citada causa de aumento de pena, a redação seria “se a venda ou entrega da droga tiver sido cometida em transporte público”. Como o legislador não restringiu, não cabe ao interprete fazê-lo.

A razão de ser da norma fora bem sintetizada pela Min. Cármen Lúcia, no HC nº 109.411/MS, Primeira Turma, DJe de 26/10/11), “[a] majorante é de natureza objetiva e, por conseguinte, aperfeiçoa-se com a constatação de ter sido o crime cometido no lugar indicado, no caso, em transporte público, independentemente de qualquer indagação sobre o elemento anímico do infrator. Naquele ambiente, é facilitada a atuação do agente, porque o maior número de pessoas presentes no interior do meio de transporte dificulta a ação fiscalizadora e, por conseguinte, facilita a disseminação da droga no meio social.”

Nesse sentido:

EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Pretensão à redução da pena no patamar máximo legalmente admissível. Dosimetria. O reexame da dosimetria implicaria a análise de prova, a qual é vedada na via processual eleita. Transporte público. Incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Tóxicos. Conduta pluriofensiva. Recurso não provido. 1. Na via do habeas corpus, o exame da dosimetria da reprimenda fica circunscrito à “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28/8/92, RTJ 143/600). 2. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08). O mesmo se dá na hipótese de pretendida majoração do redutor. 3. Por se tratar de infração pluriofensiva, o simples fato de utilizar o agente meio de transporte público para o transporte do entorpecente é suficiente para a incidência da majorante, na medida que “transportar” e “trazer consigo” são elementos do tipo penal descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, de modo que, não obstante a paciente não estivesse comercializando o entorpecente no interior daquele veículo de transporte público coletivo, a mera conduta consistente em “transportar” ou “trazer consigo” a droga por esse meio é suficiente para justificar a incidência da majorante. 4. Como destacado pela Ministra Cármen Lúcia (HC nº 109.411/MS, Primeira Turma, DJe de 26/10/11), “[a] majorante é de natureza objetiva e, por conseguinte, aperfeiçoa-se com a constatação de ter sido o crime cometido no lugar indicado, no caso, em transporte público, independentemente de qualquer indagação sobre o elemento anímico do infrator. Naquele ambiente, é facilitada a atuação do agente, porque o maior número de pessoas presentes no interior do meio de transporte dificulta a ação fiscalizadora e, por conseguinte, facilita a disseminação da droga no meio social”. 5. Recurso não provido. (RHC 115399, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 12-08-2013 PUBLIC 13-08-2013)

Ainda no mesmo sentido, julgado recente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: REDUÇÃO DA PENA PLEITEADA – AFASTAMENTO DO

AUMENTO INICIAL E APLICAÇÃO DA BENESSE DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06 - INADMISSIBILIDADE - RÉ PRIMÁRIA E SEM ANTECEDENTES - IRRELEVÂNCIA - QUANTIDADE ELEVADÍSSIMA DE DROGAS (MAIS DE 11KG) - DESLOCAMENTO DA DROGA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO - EVIDENTE VINCULAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DE MERCANCIA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES OU COOPERAÇÃO COM ELA - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500131-91.2020.8.26.0585; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Venceslau - 1ª Vara; Data do Julgamento: 16/08/2021; Data de Registro: 16/08/2021)

Esse, ademais, é o entendimento esposado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em relação a todos os demais locais indicados no dispositivo. Segundo o C. STJ, a causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas possui natureza objetiva e se aplica em função do lugar do cometimento do delito, sendo despidianda a comprovação efetiva do tráfico nos locais e nas imediações mencionados no inciso ou que o crime visava a atingir seus frequentadores.

Julgados: HC 502495/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 27/06/2019; AgRg no HC 488403/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 08/04/2019; HC 480887/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019; HC 443828/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018; HC 407487/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017; AgRg no RESp 1558551/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 19/09/2017.

Assim, a imputação ministerial em desfavor da acusada merece acolhimento.

Ausentes causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a condenação da acusada é medida de rigor, como incursa no art. 33, caput, c/c art. 40, III e V, todos da lei nº 11.343/06.

Passo, pois, à fixação de pena.

Na primeira fase, atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima, conjugadas com as circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 ("O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente"), em especial a natureza e a quantidade de substância entorpecente, entendo que a pena da acusada não deva ser fixada no mínimo legal.

No tocante à natureza, variedade e quantidade do entorpecente (artigo 42 da Lei nº 11.343/06), verifica-se que a reprimenda deve ser exacerbada, posto que, consoante comprovado nos autos, a ré tinha em seu poder mais de 16 kg de maconha.

No tocante a maconha, tem-se que a droga tem alta capacidade de tornar o usuário dependente químico, vinculando-o a uma deletéria engrenagem de consumo, onde a cada nova dose, maior quantidade se faz necessária a satisfazer o vício.

De igual norte, Renato Brasileiro de Lima: "Como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato, não se pode equiparar a conduta daquele que é preso com um quilograma de maconha com a daquele que é preso com um quilograma de cocaína, já que esta droga tem um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado que aquela" (DE LIMA, Renato Brasileiro. Legislação criminal especial comentada. 2ªed., JusPODIVM, 2014, p. 787 - destaquei).

Segundo o entendimento de NUCCI: "A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública.

Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude de sua utilização. Estes fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado" (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e



processuais penais comentadas. 4ªed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 378 - negritou-se).

Não se pode descurar do impacto que a comercialização de 16,270 kg de maconha possui na cidade do interior do Estado, notadamente se levar em conta a proporção população x usuários atendidos com a referida quantidade, bem como, abastecer os pontos de tráfico. A quantidade de entorpecentes é expressiva, o que enseja exasperação considerável da pena-base.

Os demais elementos são neutros.

Assim, à vista da argumentação acima expendida e observados os elementos constantes dos autos, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Na segunda fase da reprimenda, verifico a presença das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão previstas no artigo 65, incisos I e III, "d", do Código Penal, razão pela qual minoro em 1/3 (um terço) e fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa.

Na terceira fase, presentes as causas de aumento previstas no art. 40, III e V, da Lei n. 11.343/06.

No tocante a causa de aumento do art. 40, V, da LD, tem-se que para a incidência dessa majorante é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Julgados: AgRg no AREsp 1463715/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019; AgRg no AREsp 1251066/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019; AgRg no REsp 1780918/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019; AgRg no AREsp 1376236/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019; HC 453773/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 13/09/2018; AgRg no AREsp 580314/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018.

No presente caso, a ré efetivamente transpôs a fronteira entre os estados do Paraná e São Paulo, o que denota deslocamento razoável e maior proximidade no êxito do transporte da droga ao destino final, o que enseja recrudescimento na fração de aumento; sem descurar da incidência de outra causa majorante.

Nesse passo, majoro a pena 1/3 (um terço), resultando na reprimenda de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa.

Não há falar em aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da LD, pelos fundamentos acima expendidos, aos quais faço remissão para se evitar repetição desnecessária. Portanto, torno a pena acima definitiva.

Considerada a situação econômica da acusada, que ao que consta não goza de padrão de vida elevado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, corrigido monetariamente desde então.

No caso dos autos, em obediência ao princípio da individualização da pena, entendo não haver outro regime adequado ao início de cumprimento da reprimenda corporal de reclusão senão o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, "caput", do CP, conjugado com o art. 42 da Lei 11.343/06, haja vista a natureza e quantidade da droga apreendida, o montante de pena aplicado e as circunstâncias judiciais negativas.

Inaplicáveis os institutos dos arts. 44 e 77 do CP pelos mesmos motivos.

De se observar, ainda, que o ilícito do qual ora se trata, equiparado a hediondo, tem como principal engrenagem motora a dependência química e psíquica, principalmente por parte de jovens de diferentes classes sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de tal vício. Daí o reconhecimento da alta periculosidade da conduta, de forma que o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime mais severo permitirá a ré uma maior recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto social e a gravidade de sua conduta.

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO a ré EVELYN DA SILVA GABRIEL, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa, no mínimo unitário legal, coma incursa no artigo 33, "caput", c/c artigo 40, incisos III e V, todos da Lei nº 11.343/06.

A acusada permaneceu presa durante toda instrução processual. Os fundamentos das decisões de fls. 52/58 e 220/222, que, respectivamente, decretaram e mantiveram a prisão preventiva, permanecem válidos, tendo em vista que restam inalteradas as circunstâncias que os justificaram; razão pela qual os adoto e faço integrar a presente sentença para manutenção da custódia cautelar.

Ademais, não há nos autos comprovação de que a acusada possua emprego, muito menos trabalho com vínculo formal. Some-se a isso o fato da acusada dedicar-se às atividades criminosas, de sorte que sua manutenção em liberdade vulneraria a ordem pública pelo risco concreto de reiteração delitiva, consoante acima largamente fundamentado.

Não se pode olvidar da gravidade concreta do delito em exame, uma vez que a ré foi flagrada quando trazia consigo e transportava, para entrega a consumo de terceiros, 24 porções (seis invólucros e dezoito tijolos) de cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", pesando 16,270 kg.

Ademais, há de se ressaltar a gravidade concreta do crime, por se tratar de tráfico interestadual e cometido em transporte público.

Tais circunstâncias revelam a gravidade concreta da conduta da acusada e justificam a necessidade de manutenção da sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

É de se pontuar, além disso, que a pena aplicada à acusada foi superior a sete anos de reclusão, incompatível com seu status libertatis. Ademais, a acusada não labora com vínculo de emprego formal, exsurgindo o perigo concreto de fuga e vulneração da aplicação da lei penal.

Ressalte-se que, a despeito da primariedade da acusada, conforme entendimento pacificado do C. Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis não têm o condão de garantir a concessão de liberdade provisória:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.

[...]

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública 6. Habeas corpus não conhecido (HC 350.896/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016 – grifou-se).

Por fim, observo que a jurisprudência assim do Excelso Supremo Tribunal Federal como do Colendo Superior Tribunal de Justiça são uníssonas e remansosas no sentido de, respondendo ao feito recolhido preventivamente, com muito mais razão deverá o condenado recorrer preso cautelarmente, não havendo lógica ou razão de direito para que o faça em liberdade. Por todos: "[...] Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes." (STF RHC 117.802 Rel. Min. Ricardo Lewandowski 2ª T j. 10.06.2014 DJe 01.07.2014); "[...] no que se refere ao pleito de revogação da prisão preventiva, também não há ilegalidade, uma vez que o acórdão impugnado guarda consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não se concede o direito de recorrer

em liberdade a réu que permaneceu preso durante a instrução do processo, pois a manutenção da segregação constitui um dos efeitos da respectiva condenação, mormente quando persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar". (STJ - HC 245.975/MG 5ª T. Min. Marco Aurélio Bellizze - DJe 07.12.2012).

Pelo todo exposto, mantenho a prisão preventiva da acusada.

Recomende-se a presa no estabelecimento em que se encontra.

Decreto, ainda, nos termos do disposto no artigo 63 da Lei nº 11.343/06, a perda de eventuais valores monetários e objetos apreendidos em favor do FUNAD.

Após o trânsito em julgado:

1. Notifique-se a condenada para o pagamento de multa no prazo de 10 dias, art. 50 do CP.

2. Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para fins do disposto no art. 15, III, da CF.

3. Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD).

Expeça-se todo o necessário, fazendo as comunicações de praxe.

Por fim, condeno a ré ao pagamento das verbas a que se refere o artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

P.I.C.

Iepe, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA